

## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2018.0000786770**

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000080-29.2014.8.26.0630, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante KLEBER DA SILVA NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

**ACORDAM**, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de Kleber da Silva Nogueira, para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, fique sua pena reduzida para 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, por incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal. Determinaram que fosse providenciado o necessário para a expedição de mandado de prisão, nos termos do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no H.C. nº 126292/SP, reafirmado pelas decisões que indeferiram, por maioria de votos, as medidas cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs. 43 e 44, observando-se o regime prisional estabelecido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO RIBAS (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.

São Paulo, 4 de outubro de 2018.

**Marco Antônio Cogan**  
**RELATOR**  
**Assinatura Eletrônica**

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Apelação Criminal nº 0000080-29.2014.8.26.0630**  
**Comarca de Santa Bárbara D'Oeste – 1ª Vara Criminal**  
**MMª. Juíza dra. Camilla Marcela Ferrari Arcaro**  
**Apelante: Kleber da Silva Nogueira**  
**Apelada: Justiça Pública**  
**TJSP – Oitava Câmara de Direito Criminal**  
**VOTO Nº 36.634**

APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESES SUPLETIVAS DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 129, DO CP; DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, OU DE CONCESSÃO DO *SURSIS*, E DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 129, § 9º, DO CP.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O APELANTE NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO.

CASO EM QUE A PENA APLICADA, TODAVIA, ESTÁ A MERECER ALTERAÇÃO, A MENOR.

**Recurso parcialmente provido, com determinação.**

1 – Trata-se de apelação interposta em favor de Kleber da Silva Nogueira, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de um ano e quatro meses de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, por infração aos ditames do artigo 129, § 9º, do

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Código Penal (fls. 112/115).

Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, diante da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando que, no caso vertente, deram-se “lesões recíprocas iniciadas por ato da vítima, ocorridas no calor da discussão” (fl. 140). Supletivamente requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do *sursis*, e a fixação de regime prisional aberto para o cumprimento da corporal (fls. 139/142).

O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 145/149).

E a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do doutor Maurício da Silva, se pronunciou, igualmente, pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da decisão monocrática (fls. 154/156).

Este, em síntese, é o relatório.

2 – Por primeiro depreende-se que na parte

## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

dispositiva da sentença, a fl. 115, em evidente erro material, constou a reprimenda de um ano e quatro meses de reclusão, ao invés de um ano e quatro meses de **detenção**, o que fica aqui observado e corrigido.

No mérito, há que se dar parcial provimento ao recurso.

A materialidade está comprovada pela juntada do laudo de exame de corpo de delito de fl. 11, demonstrativo de que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em equimoses na região orbitária esquerda e na nasal anterior.

E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.

Na Delegacia ele declarou que teve um relacionamento amoroso por quatro anos com a vítima, e que mesmo após o término, ela continuou frequentando sua casa, dizendo que precisava de ajuda, pois estava com “problemas psicológicos”. Disse que certo dia ficou sabendo que ela estava namorando um policial militar, por isso se dirigiu até a residência dela, a fim de esclarecer a situação, sendo que quando foi estacionar o seu veículo na via pública, acidentalmente encostou o seu carro na motocicleta de propriedade do irmão da ofendida, derrubando-a, momento em que essa saiu de dentro do imóvel, nervosa, e repentinamente investiu

## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

contra a sua pessoa, tentando esgana-lo, daí porque, buscando se defender, deu um soco no rosto dela, que caiu ao solo, oportunidade em que se retirou do local (fl. 10).

Em Juízo não compareceu para o seu interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia (fl. 108).

E a vítima Cássia Elaine dos Santos, por sua vez, declarou que teve um relacionamento amoroso com o apelante por um tempo, mas que na época dos fatos já estavam separados. Relatou que no dia em questão, na parte da manhã, o acusado viu um amigo seu saindo de sua casa, e não gostou, tendo retornado posteriormente, exigindo maiores explicações a respeito daquele homem. Contou que ficou conversando com o réu na calçada, em frente a sua residência, pois não queria deixa-lo entrar, e pediu para que o mesmo fosse embora, até que em um determinado momento ele, repentinamente, a agrediu com vários socos no rosto, chegando inclusive a quebrar o seu nariz (mídia).

Por derradeiro, a testemunha Fábio Vieira dos Santos, irmão da ofendida, narrou que no dia dos fatos resolveu guardar a sua motocicleta dentro do imóvel, depois que o réu a derrubou com o veículo dele, oportunidade em que viu que sua irmã estava saindo de casa, indo ao encontro do acusado, para conversar

## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

com ele. Afirmou que pouco depois escutou gritos, tendo então ido em direção ao local onde a vítima se encontrava, presenciando o réu dando socos no rosto dela. Ressaltou que assim que o acusado o avistou, ele empreendeu fuga em seu automóvel. Salientou que sua irmã ficou bastante machucada por conta das agressões sofridas (mídia).

Diante desse cenário, patente que o teor da prova pericial já citada, aliada à oral, consistente na versão da vítima, que foi corroborada *in totum* pelo depoimento da testemunha Fábio, sobre o qual nenhuma comprovação foi feita de que tivesse interesse em prejudicar o recorrente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal, parcialmente corroborada pelas declarações extrajudiciais do próprio réu que admitiu, na única oportunidade em que foi ouvido, quanto a ter agredido fisicamente a ofendida, com um soco no rosto (embora alegando que agiu em legítima defesa), bem justificaram a condenação recepcionada no édito monocrático.

Evidente, assim, que não houve, no caso em comento, meras agressões recíprocas, tampouco se configurou legítima defesa por parte do apelante, ou a forma privilegiada do delito, prevista no § 4º, do artigo 129, do Código Penal, como aduzido pela Defesa, por não existir nos autos nem mesmo indícios de que tenham ocorrido, observando-se que a insubsistente versão

## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

exculpatória do acusado, apresentada tão somente na fase inquisitiva, restou completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não ter sido comprovada, como bem exige a disciplina do artigo 156, do Estatuto Adjetivo, não tendo, assim, o condão de se sobrepor àquela fornecida pela ofendida, que narrou sobre a dinâmica dos fatos de forma clara e coesa, nas duas ocasiões em que foi ouvida, inclusive em Juízo, sob o crivo do contraditório, ainda respaldada, repita-se, pelo depoimento judicial da testemunha Fábio.

Aliás, com efeito, a vítima suportou lesões corporais, constatadas pela prova técnica já mencionada, enquanto o apelante sequer foi submetido a exame de corpo de delito, ou deu qualquer demonstração de que tivesse sofrido ferimentos de mesma monta, acrescentando-se a isso, ainda, que se mostra evidente a desproporcionalidade entre a invocada **tentativa** da ofendida em “esgana-lo”, jamais comprovada, e os inúmeros socos que ele desferiu contra o rosto dela, não existindo nessa atitude o requisito moderação, o que bem demonstra o dolo com que ele agiu, e a intensidade desse.

Não há que se falar, pois, em absolvição por ausência de provas, ou por incidência de qualquer excludente de ilicitude, sendo de rigor a condenação do acusado na forma recepcionada no édito monocrático.

A pena, contudo, comporta reparo.

## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Isso porque, ainda que se utilize quatro condenações anteriores do acusado para caracterizar seus péssimos antecedentes (certidões de fls. 78, 82, 83 e 84), a fim de ser fixada a pena básica acima do patamar mínimo, da forma como procedeu a julgadora monocrática, observa-se que se mostra excessivo o aumento em mais que o triplo do mínimo legal, daí porque fica reduzida essa majoração para 1/3.

Saliente-se, por oportuno, que o apelante foi absolvido no processo nº 13735/2008 (certidão de fl. 79), que também foi utilizado pela MMª. Juíza na dosimetria da pena, o qual deve ser, portanto, desconsiderado.

Dessa forma, na segunda fase, restando apenas duas condenações anteriores definitivas aptas a ensejar reincidência (processos nºs 3379/2010 e 783/2015 – fls. 56/57), ficam as reprimendas exasperadas na fração de 1/5, por essa agravante, e não em 1/3, como se deu na r. sentença.

Nesses termos, fixada a pena básica em 1/3 acima do mínimo legal, e a seguir exasperada em 1/5, conforme acima analisado, fica a final estabelecida em quatro meses e vinte e quatro dias de detenção.

E diante dos péssimos antecedentes e da



**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

reincidência do apelante, se mostra inviável a concessão da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ou mesmo do *sursis*, como pleiteado pela Defesa, a teor do disposto nos artigos 44, I, II e III, e 77, I e II, ambos do Código Penal, acrescentando-se que o primeiro instituto citado inclusive é vedado em casos de violência doméstica, como na espécie, sendo o regime prisional inicial semiaberto estabelecido o mais adequado, também, à luz dos ditames do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de **Kleber da Silva Nogueira**, para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, fique sua pena reduzida para 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, por incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal. Providencie-se o necessário para a expedição de mandado de prisão, nos termos do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no H.C. nº 126292/SP, reafirmado pelas decisões que indeferiram, por maioria de votos, as medidas cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs. 43 e 44.

**Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan**  
Relator